

< 제48회 특허법 해설 >

안녕하세요. 합격의 법학원 김 성호 변리사입니다. 2차 시험을 치르시느라 고생하신 수험생 분들께 조금이나마 도움이 될 수 있도록 올해 특허법 문제에 대한 나름의 목차와 답안을 작성해 보았습니다. 부족한 실력과 급한 성격(?)으로 말미암아 다소 놓친 논점 내지는 불필요한 논점이 추가될 수 있는 점 널리 양해 바라며, 제가 드린 해설은 100% 제 주관적인 견해로 작성된 부분임으로 충분히 다른 관점에서 달리 작성될 가능성도 있는 답안임을 강조 드립니다. 아무쪼록, 답안을 복기하고 검토하시는 과정에 있어서 미력하나마 도움이 되길 바라는 마음 뿐입니다. 그 동안 시험준비 하시느라, 이틀 동안 힘든 시험 치르시느라 정말 너무 고생 많으셨습니다.

<A-1문> : 진보성에 관한 일반론을 쓰는 문제로서, 설문 (1)과 설문 (2) 모두 심사지침서 상의 내용을 그대로 문제화 한 것으로 보입니다. 진보성에 관한 문제는 주관적 판단을 요구하는 만큼 실질적인 사례문제에 대해서는 개개인마다 그 판단이 현저히 달라질 수 있는 만큼, 이렇게 단문 형식으로 출제된 것 같습니다. 특히 설문 (2)의 PBP청구항의 진보성 판단방법은 작년 기출에 포함된 부분인 만큼 전혀 준비하지 않으신 분은 당황하실만한 부분이라고 보입니다. 각 설문의 문제에서 논점을 잡아주고 있는 만큼 문제의 소재는 과감히 제외하였습니다.

I. 설문 (1)에 대하여(15) - 진보성의 판단기준 및 방법

1. 진보성의 의미 및 취지

특허출원 전에 당업자가 공지 등이 된 발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 경우에는 특허를 받을 수 없다. 진보성이 없는 발명에 독점·배타권을 부여하는 것은 산업발전에 이바지한다는 법 목적에 반하기 때문이다.

2. 진보성 판단의 일반적인 순서 - 설문 (1)의 해결

①우선, 청구항에 기재된 발명을 특정한 후, ②진보성 판단의 근거가 되는 인용발명을 특정한다. 이 경우, 복수의 인용발명을 특정하는 것도 가능하다. ③청구항에 기재된 발명과 인용발명을 선택하고 양자를 대비하여 그 차이점을 명확히 한다. 이 경우 발명을 이루는 구성요소 중 유기적으로 결합된 일체로서 인용발명의 대응되는 구성요소와 대비한다. ④인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명에 이르는 것이 통상의 기술자에게 용이한지 여부를 판단한다.

3. 용이도출 여부의 판단방법에 대한 구체적 설명 - 설문 (1)의 해결

(1) 일반적 판단방법

1) 진보성의 유무는 목적의 특이성·구성의 곤란성·효과의 현저성 여부로 판단한다.

2) 인용발명으로부터 출원발명으로 이르게 된 것이 당업자에게 자명한가 여부로 판단한다. 특히 ①발명에 이를 수 있는 동기가 있는 것, ②당업자의 통상의 창작능력의 발휘에 해당하는 것인지 및 ③더 나은 효과가 발생하는지를 고려한다.

3) 특히, 발명의 완성과정이나 대응되는 외국특허는 참작의 대상이 될 수 없으며, 특히 대법원 判例는, 상업적 성공여부 및 장기간 미해결과제의 해결 등을 참작할 수 있으나 그 자체만으로 진보성이 있다고 단정할 수는 없다고 판시하고 있다.

(2) 구체적인 판단방법

1) 발명에 이를 수 있는 동기가 있는 것

인용발명의 내용 중에 청구항에 기재된 발명에 대한 사사가 있는 경우, 인용발명과 청구

항에 기재된 발명의 과제가 공통되는 경우, 기능·작용이 공통되는 경우, 기술분야의 관련성이 있는 경우 등은 통상의 기술자가 인용발명에 의하여 청구항에 기재된 발명을 용이하게 발명할 수 있다는 유력한 근거가 된다.

2) 통상의 기술자의 통상의 창작능력의 발휘에 해당하는 것

공지기술의 일반적인 응용, 알려진 물리적 성질로부터의 추론, 알려진 과제의 해결을 위한 다른 기술분야 참조 등으로 일상적인 개선을 이루는 것은 통상의 기술자가 가지는 통상의 창작능력의 발휘에 해당하여 용이하게 발명할 수 있다는 유력한 근거가 된다. 구체적인 유형으로, ①일정한 목적 달성을 위한 공지의 재료 중 가장 적합한 재료의 선택, ②수치범위의 최적화 또는 호적화, ③균등물에 의한 치환, ④기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계변경, ⑤일부 구성요소의 생략 및 ⑥단순한 용도의 변경 등이 있다.

3) 더 나은 효과의 고려

①청구항에 기재된 발명의 기술적 구성에 의하여 발생하는 효과가 인용발명의 효과에 비하여 더 나은 효과를 갖는 경우에 그 효과는 진보성 인정에 긍정적으로 참작할 수 있다. ②복수의 인용발명의 결합에 의하여 통상의 기술자가 용이하게 생각해 낼 수 있는 경우에도 청구항에 기재된 발명이 인용발명이 가진 것과는 이질 또는 동질이라도 현저한 효과를 가지며, 이러한 효과가 당해 기술수준으로부터 통상의 기술자가 예측할 수 없는 경우에는 진보성이 인정될 수 있다.

II. 설문 (2)에 대하여(15) - 특유발명에 대한 진보성 판단방법

1. 선택발명에 대한 진보성의 판단방법(5) - 설문 (2)의 해결

(1)선택발명이란, 선행발명을 상위개념으로 할 때 하위개념의 관계에 있는 발명을 말한다. 기초발명의 활용을 통해 산업발전에 이바지하기 위한 취지에서 인정된다.

(2)대법원 判例는, 선택발명의 진보성이 인정되기 위해서는 선택발명을 구성하는 하위개념 모두가 인용발명과 질적으로 다른 효과를 가지고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 한다고 판시한다.

(3)또한, 심사지침서에 따르면 최적 또는 호적의 선택정도가 당업자의 통상의 창작능력의 발휘에 해당하면 진보성이 인정되지 아니하나, 선택발명이 인용발명에 비해 유리한 효과를 가지는 경우 진보성이 인정된다고 한다.

(4)한편 대법원 判例는, 선택발명의 상세한 설명에는 인용발명에 비해 현저한 효과가 있음을 명확히 기재하면 충분하고, 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재해야 하는 것은 아니며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원인이 구체적인 비교실험자료

를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 주장 입증하면 된다고 판시한다.

2. 결합발명에 대한 진보성의 판단방법(5) - 설문 (2)의 해결

(1)결합발명이란, 발명의 기술적 과제를 달성하기 위하여 선행기술들에 기재된 기술적 특징을 종합하여 새로운 해결수단으로 구성한 발명을 말한다.

(2)대법원 判例는, 청구항이 복수의 구성요소가 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 결합발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다고 판시한다.

(3)일반적으로 결합발명은 기술적 특징 간의 기능적 상호 작용으로 인해 개개의 특징의 기술적 효과의 합과는 다른, 예를 들어 더 큰 복합적인 상승효과를 달성하는 경우, 기술적 특징의 집합을 기술적으로 의미있는 조합으로 간주하여 진보성을 인정할 수 있다.

3. 제법한정물건발명에 대한 진보성의 판단방법(5) - 설문 (2)의 해결

(1)제법한정물건발명이란, 물건에 관한 발명을 구성이 아닌 방법으로 특정한 발명을 말한다.

(2)심사실무는 보호받고자 하는 발명은 방법이 아니라 물건으로서 그 물건 자체로 등록요건을 심사한다.

(3)判例도, 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 특단의 사정이 없는 한, 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서 제조방법을 고려 할 필요 없이 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전의 공지기술과 대비하여 판단하면 된다고 판시한다.

(4)보호받고자 하는 것 자체가 물건이고, 명확한 물건발명의 카테고리를 가지고 있는 것이므로 등록요건 판단대상은 물건 그 자체로 해석하는 것이 타당하다. 따라서 심사관은 신규성이나 진보성 판단 등에 있어 그 방법이나 제조장치가 특허성이 있는지 여부를 판단하는 것이 아니라 그러한 방법으로 제조된 물건 자체의 구성을 공지기술과 비교하여 진보성이 있는지 여부를 판단한다. 이 경우 방법에 의해 물상·특성·구조 등을 포함하여 특정되는 물건이 판단의 대상이 된다.

<A-2문> : 독립항과 종속항의 구별기준에 대한 일반론 및 사안의 적용과, 실무적인 문제인 각 청구항의 진보성 판단에 대한 비교적 간단한 문제였습니다. 특히 설문 (2)에서의 청구항 3항의 항 종류의 판단이 가장 난해하였던 것으로 보이며, 줄견으로 심사지침서의 내용을 참고하여 종속항으로 판단하였습니다. 본 설문은 배점을 고려하여 각 청구항 별로 목차를 잡아주는 방식도 필요할 것으로 보입니다. 역시 각 설문의 문제에서 논점을 잡아주고 있는 만큼 문제의 소재는 과감히 제외하였습니다.

I. 설문 (1)에 대하여(5) - 특허법 시행령 제5조 1항의 검토

1. 특허청구범위의 기재방법

우리 특허법은 다항제를 채택함으로써 출원인의 보호에 적정을 기하고 있는데, 특허청구범위의 기재방법에 대하여는 제42조 8항 및 특허법 시행령 제5조에서 필요한 사항을 규정하고 있다.

2. 독립항과 종속항을 구분하는 일반적인 기준 - 설문 (1)의 해결

(1)특허청구범위에는, ①독립항을 기재하고 ②그 독립항을 인용하는 형식으로 한정·부가하여 구체화하는 종속항으로 기재하며, 그 종속항을 한정·부가하여 구체화하는 다른 종속항으로 기재할 수 있다.(특허법 시행령 제5조 1항)

(2)특히 종속항은, ①형식적으로 인용하는 형식이면서, ②실질적으로 인용되는 항을 한정·부가하고 있어야 하는데, ③다만 대법원 判例는, 비록 인용하는 형식을 취했을 지라도 인용되는 항을 실질적으로 한정·부가하여 구체화하는 것이 아니라면 독립항으로 보아야 한다고 판시한다.

(3)따라서, ①인용되는 항의 구성요소를 감소시키는 형식으로 기재하는 경우 및 ②인용되는 항에 기재된 구성을 다른 구성으로 치환하는 형식으로 기재하는 경우 등은 독립항으로 취급된다.

II. 설문 (2)에 대하여(8) - 각 청구항의 형태 구별

1. 청구항 1의 판단 - 독립항

청구항 1은, 다른 청구항을 인용하지 않는 형식으로 기재되었는바 명백한 독립항에 해당한다.

2. 청구항 2의 판단 - 종속항

청구항 2는, ①'제1항에 있어서'라는 표현에서 독립항인 제1항을 인용하는 형식을 취하고 있으며, ②제1항 발명의 구성요소인 노즐의 분사구의 형태를 '원형'으로 한정하고 있으므로 종속항에 해당한다.

3. 청구항 3의 판단 - 종속항

(1)청구항 2의 종속항에 해당하는지 여부

청구항 3은 ①'제2항에 있어서'라는 표현에서 종속항인 제2항을 인용하는 형식을 취하고 있으나, ②제2항의 노즐의 분사구의 형태를 '사각형'인 것으로 치환하는 형식으로 기재되었는바, 청구항 2의 종속항에는 해당하지 않는다.

(2)청구항 1의 종속항에 해당하는지 여부

1)심사지침서에 의하면, 종속청구항이란 발명의 내용이 다른 항에 종속되어 다른 항의 내용변경에 따라 해당 청구항의 발명의 내용이 변경되는 청구항을 말한다.

2)청구항 3은, ①제2항을 인용하고 있으나, 제2항이 제1항을 인용하는 형식을 취하고 있어 실질적으로 제1항을 인용하는 형식으로 기재되었다고 볼 수 있으며, ②발명의 내용이 제1항에 종속되어, 발명의 구성요소인 노즐의 분사구의 형태를 '사각형'으로 한정하는 것이므로, 제1항의 내용변경에 따라 제3항의 발명의 내용도 변경되는바, 종속항에 해당한다.

4.청구항 4의 판단 - 독립항

청구항 4는, ①'제1항에 있어서'라는 표현에서 독립항인 제1항을 인용하는 형식을 취하고 있으나, ②제1항 발명의 구성요소인 '복수 개의 노즐'이 '노즐이 하나인 것'으로 치환되는 형태로 기재되었는바, 判例에 의할 때 독립항에 해당한다.

III.설문 (3)에 대하여(7) - 독립항과 종속항의 진보성 판단방법

1.진보성의 의의 및 취지

특허출원 전에 당업자가 공지 등이 된 발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 경우에는 특허를 받을 수 없다. 진보성이 없는 발명에 독점·배타권을 부여하는 것은 산업발전에 이바지한다는 법 목적에 반하기 때문이다.

2.각 청구항 별 진보성 판단의 상호관계의 검토 - 설문 (3)의 해결

(1)문제점

제1항과 제4항은 독립항이고, 제2항과 제3항은 제1항의 종속항이며, 제4항은 종속항이 별도로 존재하지 않는바 그 자체의 판단으로 충분한 바, 제1항, 제2항 및 제3항의 상호관계를 중심으로 검토한다.

(2)독립항과 종속항에 대한 진보성 판단방법의 일반적인 기준

대법원 判例는, 독립항의 진보성이 인정되는 경우에는 그 독립항을 인용하는 종속항도 진보성이 인정되나, 독립항의 진보성이 인정되지 않는 경우에는 그 독립항에 종속되는 종속항에 대하여는 별도로 진보성을 판단하여야 한다고 판시한다. 심사지침서도 동일하다.

(3)제1항의 진보성이 인정되는 경우

독립항이 진보성이 인정되는 경우로서 종속항도 진보성이 인정되므로 제2항 및 제3항에 대한 별도의 판단 자체가 불요되어 진보성이 인정되게 된다.

(4)제1항의 진보성이 인정되지 않는 경우

독립항이 진보성이 인정되지 않는 경우로서 종속항의 진보성은 별도로 판단되어야 하므로 제2항 및 제3항이 선행기술에 비해 진보성이 인정될 수 있는지 여부를 개별적으로 판단한다.

<B-1문> : 설문 (1)은, 2011년 6월 9일의 최신 대법원 판례가 반영된 문제이며, 설문 (2)는, 전용품인지의 여부도 권리범위확인심판의 대상이 될 수 있는지에 대한 사례형 문제였습니다. 특히 설문 (2)에서, 타용도 없음이 문제에서 주어진 만큼 구체적인 판단이 불필요하게 됨으로써 실제 시험에서 접하게 되는 사례형 문제로 보기에는 배점에 비해 논점이 다소 적은 문제로 볼 수 있다고 보입니다. 따라서 전용품에 대한 일반론에 대한 일정정도 이상의 기재가 필요한 문제라고 생각되고, 특히 설문 (2)의 생산의 의미와 관련한 判例는 사안의 해결과는 크게 관계 없는 일반론 정도로 취급해 주시면 되겠습니다.

I. 설문 (1)에 대하여(10) - 제30조의 적용가부에 대한 判例의 검토

1. 문제의 소재

乙의 무권리자 출원 해당여부 및 출원발명인 방법 K의 신규성 상실여부를 검토하고, 제30조의 적용가부에 있어서 취지 기재의 추후 보정이 가능한지와 관련하여 判例의 태도를 검토한다.

2. 乙 출원의 거절이유의 검토 - 무권리자 여부 및 신규성 상실여부

(1) 乙은 방법 K를 독자적으로 발명한 丁으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 양수하여 특허 출원 한 자로서, 다른 사정이 없는 한 제33조 1항 본문의 승계인에 해당하는바, 문제되지 않는다.

(2) 또한, ①방법 K는 그 자체에 신규성이 인정되면 족하고 그 방법에 의해 생산된 물건의 신규성은 불요하므로 甲 특허발명의 존재는 문제되지 않으나, ②방법 K가 乙의 출원일 이전인 2009.5.2.에 丁의 논문을 통해 발표되었는바, 제29조 1항 1호 전단 또는 2호 전단의 행위로서 방법 K는 신규성을 상실하였다. 따라서, 원칙적으로 제29조 1항 각호 위반의 거절이유를 가진다.

3. 제30조 주장이 적법한지 여부 - 취지 기재의 누락을 출원 이후 보정할 수 있는지 여부

(1) 공지에외주장이란, ①특허출원 전에 이미 공지 등이 된 발명이라도 제30조의 일정한 요건을 갖춘 경우 신규성·진보성의 판단 시 공지 등이 되지 않은 것으로 간주하는 제도이며, ②의사에 의한 공지인 경우, 공지된 날로부터 6월 내 출원이어야 하며, 출원 시 출원서에 취지를 기재하고, 출원일로부터 30일내에 증명서류를 제출하여야 한다. ③또한, 공개자와 출원인이 각각 丁과 乙로 다른 경우라도, 추후 증명서류의 제출을 통해 의사에 기한 공지 후 특허를 받을 수 있는 권리의 적법한 승계임을 주장하면 의사에 의한 공지로 인정받을 수 있다.

(2) 제30조 주장의 취지·기재 서면의 추후보정의 가부 - 判例의 태도

1) 특허법원이, 취지 기재의 추후 보정을 허용하더라도 ①제33조의 권리에 부당한 영향이 없는 점, ②제30조 1항 규정의 취지 및 ③의사에 반한 공지와의 형평을 이유로 출원일 이후 취지 기재의 보정을 허용한 것에 대해,

2)대법원 判例는 최근 판시를 통해, 취지를 기재하지 아니하고 출원하였으므로 그 후 자기 공지 예외 규정에 해당한다는 취지를 기재한 서면을 제출하더라도 제30조 1항 1호가 적용될 수 없다고 판시하면서 상기 判例를 파기 환송하였는바, 추후 보정을 불허하는 태도이다.

(3)법적안정성을 고려할 때 대법원 判例가 타당한바, Z은 출원 시 취지를 기재하지 않은 이상 추후 보정도 불가하므로, 제30조 주장은 부적법하다.

5.Z의 출원의 특허등록 가능성의 검토 - 설문 (1)의 해결

따라서, Z의 출원은 丁의 공개행위에 의한 신규성 상실로 등록 불가할 것이다. 다만, 현재 丁의 공지일로부터 6월이 경과되지 않은 것이라면 조속히 취하 후 제30조 주장을 새로이 수반하여 재출원 함으로써 방법 K를 등록받는 방안이 검토될 수 있을 것이다.

II.설문 (2)에 대하여(20) - 권리범위확인심판의 심리대상 및 전용품에의 해당여부

1.문제의 소재

①심판청구의 적법성과 관련하여, 전용품인지 여부가 심리대상이 될 수 있는지 여부를 검토하고, ②甲의 주장의 인용여부와 관련하여, a+b가 특허발명의 생산에만 사용되는 전용품에 해당하는지 여부를 검토한다.

2.권리범위확인심판의 의의 및 취지(제135조)

특허분쟁에 대한 사전적 예방수단으로서, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는가의 여부를 공적으로 확인하기 위하여 특허권자, 전용실사권자 및 이해관계인이 청구할 수 있는 심판을 말한다.

3.권리범위확인심판의 적법성 검토 - 설문 (2)의 해결

(1)적법요건과 관련하여, ①특허권자인 甲이, ②확인대상발명의 실시자인 Z을 상대로, ③특허권의 존속기간 내에 청구하였으나, ④확인대상발명이 특허발명의 생산에만 사용되는 물건(이하 '전용품')에 해당하는지 여부를 심리하여야 하는지가 문제된다.

(2)대법원 判例는, ①권리범위확인청구는 단순히 그 발명의 기술적 범위를 확인하는 사실확정을 목적으로 한 것이 아니라 특허권의 효력이 미치는지의 여부를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것이라고 판시하며, ②또한, 특허발명이 제조장치를 사용하여 물건을 제조하는 방법발명일 때, 확인대상발명의 제조장치가 청구항 발명의 실시에만 사용되는 장치인지 여부를 제135조의 심판으로 판단할 수 있다고 판시하여, 간접침해물품에 대한 본 심판청구를 긍정한다.

(3)따라서, 본 심판청구는 심리대상에 있어 적법한 것이며, 심판원은 전용품인 a+b로서 확인대상발명이 적법하게 특정되었다면, 전용품 해당하여 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부에 대

한 심리를 하여야 할 것이다.

4. 甲의 주장의 인용여부에 대한 검토 - 설문 (2)의 해결

(1) 권리범위확인심판의 심결내용

적극적 권리범위확인심판의 경우, 특허발명의 권리범위에 속한다고 판단된 경우에는 인용 심결을 하며, 속하지 않는다고 판단된 경우에는 기각심결을 한다.

(2) 구성요소완비의 원칙 상 보호범위에 속하는지 여부

1) 특허청구범위에 기재된 구성요소 전부를 실시하는 경우에만 보호범위에 속한다는 이론을 말하며, 구성요소 전부를 실시하는 지 여부는 발명의 일체성을 가지고 기술적 사상이 그대로 포함되는지 여부를 실질적으로 판단한다.

2) 사안의 경우, $a+b$ 의 실시만으로는 특허발명의 구성요소 전부인 $a+b+c$ 를 실시하는 것으로 볼 수 없는바 구성요소완비의 법칙만 고려할 때 권리범위 내의 실시는 아니다.

(3) 전용품에 해당하는지 여부

1) 제127조는 특허발명의 생산에만 사용되는 물건에 대하여도 침해를 주장할 수 있음을 규정하여 특허권자의 실효적 보호를 도모하고 있다.

2) 전용품이란, 특허발명의 물건의 생산에만 사용되는 물건 즉, 타용도가 없음을 의미하는 것으로서 이는 특허권자가 주장 입증하여야 한다.

3) 대법원 判例는, 제127조의 '생산'이란 특허발명의 구성요건의 일부를 결여한 물건을 사용하여 특허발명의 모든 구성요소를 충족하는 물건을 새로 만들어 내는 모든 의식적 행위를 의미하므로 반드시 공업적 생산에 한정하지 않고 가공 조립 수리 등의 행위도 포함된다고 판시한다.

4) 사안의 경우, $a+b$ 가 $a+b+c$ 의 생산에만 사용되는 물건으로서, 구성요소 일부를 결여한 $a+b$ 가 丙에 의해 모든 구성요소를 갖춘 $a+b+c$ 만이 생산되고 있는 것으로 미루어 보아 다른 용도가 존재하지 않으므로, 乙의 $a+b$ 는 $a+b+c$ 의 발명의 생산에만 사용되는 전용품에 해당한다.

(4) 따라서, 심판원은 전용품에 해당하는 $a+b$ 의 확인대상발명이 甲 특허발명의 권리범위에 속한다는 인용심결을 내릴 수 있으므로 다른 사정이 존재하지 않는 한 인용 될 것이다.

<B-2> : 기출예상으로 많이 손꼽히던 문제가 나왔습니다. 특허권의 공유자 중 1인의 심결취소소송의 제기가 아닌 2인이 공동으로 제기한 무효심판에 있어서 당사자 적격에 관한 문제가 먼저 기출 되었습니다. 설문 3가지 모두가 '지적재산소송실무'의 P.20 ~ P.23의 내용을 그대로 문제화 하였다고 보아도 과언이 아닐 정도로 그대로 출제되었습니다. 이와 관련하여 목차구성은, 각 심결의 내용에 따른 심결취소소송의 원고 및 피고적격을 검토하는 문제로서 설문 모두가 공동심판의 법적성질과 관련하여 문제가 되므로, 공통적인 견해대립 부분을 먼저 검토한 후 설문별로 해결하는 것이 가장 무난하겠습니다. 다만, 당사자 적격에 한하여만 묻고 있으나 배경이 비교적 큰 점을 고려할 때 判例에 대한 정확한 암기와, 추가적인 논의로 누락된 당사자의 추가 또는 구제책에 대한 논의도 필요할 것이라고 생각됩니다.

I. 문제의 소재 - 심결취소소송의 의의 및 취지 등

1. 심결취소소송이란, 심결에 대한 당사자 등이 특허심판원의 행정처분인 심결에 대하여 특허법원에 그 취소를 구하는 소를 말한다. 행정처분의 위법성을 소송을 통해 불복하여 권익을 피하기 위함이다.

2. 심결취소소송의 당사자 적격은, ①심판사건의 당사자 참가인 또는 당해 심판이나 재심에 참가 신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자가 원고적격을, ②당사자계 심판사건의 경우에는 심판의 청구인 또는 피청구인이 피고가 된다.

3. 다만, 제139조 1항은 동일한 특허권에 관하여 무효심판을 청구하는 자가 2인 이상이 있는 때에는 그 전원이 공동으로 심판을 청구할 수 있다고 규정하는데, 각 설문에서는 이렇게 청구된 무효심판의 인용 또는 기각심결에 대해 공동심판청구인 중 일부만이 심결취소소송의 원고 내지 피고가 될 수 있는지 여부가 공동소송의 법적성질과 관련하여 문제된다.

II. 공동심판의 심결취소소송의 성격에 대한 논의

1. 학설의 대립

①분쟁의 자주적 해결을 위해 이를 통상공동소송으로 보아야 한다는 통상공동소송설, ②심결의 대세효 및 일사부재리를 근거로 유사필수적공동소송으로 보아야 한다는 유사필수적공동소송설 및 ③일사부재리가 적용되는 경우에 한하여 유사필수적공동소송이라고 보는 견해 등이 대립한다.

2. 判例의 태도

①특허법원은, 심결취소소송의 당사자 아닌 자에 대한 심판청구에 대한 부분은 심결취소소송의 제소기간의 도과로 이미 확정되었고, 특허를 무효로 한다는 심결에 대한 취소소송의 계속 중

다른 사건에서 그 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 원고로서는 그 심결의 취소를 구할 법률상 이익도 없어졌다고 판시하여 통상 공동소송으로 보았으나, ②대법원 判例는 2인 이상이 공동으로 특허발명의 무효심판을 청구하여 인용심결을 받은 경우, 특허권자가 공동심판청구인 중 일부만을 대상으로 심결취소소송을 제기하였다 하더라도 그 심결은 모두 확정차단 된다고 판시하면서 유사필수적공동소송으로 보았다.

III. 설문 (1)의 해결 - 법적성질

상기 논의를 검토할 때, ①2인 이상이 공동으로 심판을 청구한 이상 심결의 모순저축을 방지하기 위해 합일확정의 필요성이 있는 점 및 ②특허권의 대세적 효력을 고려할 때 유사필수적공동소송으로 보는 견해 및 대법원 判例가 타당하다고 본다. 현재 통설의 입장이다.

IV. 설문 (2)의 해결 - A 및 甲의 당사자 적격 및 누락된 Z의 추가 가부

1. 먼저, 특허권자 A는 심결의 당사자로서 원고적격이 인정되고, 유사필수적공동소송설 및 상기 대법원 判例에 의하는 한 甲 단독에 대한 심결취소소송의 제기는 피고적격을 갖추었는바, 당사자 적격은 문제되지 않을 것이다.

2. 한편, 누락된 당사자인 Z를 피고로 추가할 수 있는지와 관련하여 대법원 判例는, 고유필수적 공동소송이 아닌 사건에서 소송 도중에 당사자를 추가하는 것은 허용될 수 없고, 동일한 특허권에 관하여 2인 이상의 자가 공동으로 특허의 무효심판을 청구하여 승소한 경우에 그 특허권자가 제기할 심결취소소송은 심판청구인 전원을 상대로 제기하여야만 하는 고유필수적공동소송이라고 할 수 없으므로, 나머지 공동심판청구인을 피고로 추가하는 신청은 부적법하여 허용될 수 없다고 판시하였는바, Z의 추가는 불가할 것이다.

3. 다만, 심결이 취소되는 경우 심결취소소송을 제기하지 않은 Z은 다시 심리가 속행되는 심판 절차에 당사자로서 참여할 수 있을 것이다.

V. 설문 (3)의 해결 - 甲 및 A의 당사자 적격의 검토 및 누락된 Z의 구제책

1. 제139조 1항의 규정에 의하면 이들의 공동심판청구는 유사필수적 공동심판의 성격을 가지므로, 공동심판청구인 중 1인인 甲의 심결취소소송의 제기도 원고적격을 갖춘 적법한 것으로 볼 수 있으며, 특허권자 A는 심결의 당사자로서 피고적격을 갖추었는바, 당사자 적격은 문제되지 않을 것이다.

2. 한편, 공동심판청구인 중 1인인 甲만이 심결취소소송을 제기하였는데, 그 후 Z도 심결취소소

<제48회 특허법 해설 - 김 성호 변리사>

송을 제기하려는 경우, ①제소기간 내 라면 공동소송참가가 가능할 것이고, ②별소를 제기하면 특허법원은 변론을 병합하여 공동소송으로 심리하게 될 것이다. ③그러나 제소기간이 경과된 경우에는 보조참가를 할 수 있을 뿐이다.